

[שם המוסד האקדמי]
הפקולטה למשפטים

עבודה סמינריונית

הכרעה בזכויות במקרקעין לא רשומים בסכסוכים פנים-משפחתיים בחברה הערבית

עיון במשפט הישראלי ובמשפט משווה: המשפט המקובל, המשפט המצרי
והמשפט השרעי האסלאמי

מגיש/ה: _____
מספר זהות: _____
שם הקורס: _____
בהנחיית: _____

אלול התשפ"ו • אוגוסט 2026

הערות השוליים והביבליוגרפיה ערוכות על פי כללי האזכור האחד בכתובה המשפטית (מהדורה שלישית, 2021)

תוכן עניינים

מבוא

שיטת המקרקעין הישראלית מושתתת על עקרון הרישום הקונסטטוטבי: עסקה במקרקעין טעונה רישום, והיא נגמרת ברישום בלבד.¹ ואולם, המציאות הקניינית בישראל – ובחברה הערבית בפרט – רחוקה מן האידיאל הרישומי. חלק ניכר מן המקרקעין ביישובים הערביים מוחזק ומועבר מדור לדור על יסוד הסכמות בעל־פה, יפוי כוח בלתי חוזרים ישנים, חלוקות משפחתיות בלתי כתובות והחזקה רבת־שנים, בלא שהעסקאות הושלמו ברישום בפנקסי המקרקעין ולעיתים אף בלא שדווחו לרשויות המס. כאשר פורץ סכסוך בתוך המשפחה – בין אחים, בין יורשים או בין דורות – נדרש בית המשפט להכריע בזכויות על יסוד תשתית ראייתית חסרה, שבמרכזה מסמכים ישנים, עדויות בעל־פה וראיות נסיבתיות.

עבודה זו בוחנת כיצד מכריעים בתי המשפט בישראל בזכויות במקרקעין לא רשומים בסכסוכים פנים־משפחתיים בחברה הערבית, ומציבה את הדין הישראלי בהקשר השוואתי רחב: המשפט המקובל האנגלי, המשפט המצרי והמשפט השרעי האסלאמי. הבחירה בשלוש שיטות אלה אינה מקרית. המשפט המקובל הוא מקור הניקה ההיסטורי של דוקטרינת הזכויות שביושר במשפט הישראלי;² המשפט המצרי מייצג שיטה ערבית מודרנית בת־זמננו המתמודדת עם שיעורי אי־רישום עצומים ועם פרקטיקה נפוצה של "מכר באמצעות יפוי כוח"; והמשפט השרעי – שהמג'לה העות'מאנית היא גיבושו הקודיפיקטיבי הנודע – הוא התשתית ההיסטורית והתרבותית שעליה צמחו דפוסי ההחזקה וההעברה הבלתי פורמליים הרווחים עד היום בחברה הערבית בישראל.

שאלות המחקר

העבודה נסבה על שלוש שאלות מחקר:

- א. באילו כלים משפטיים וראייתיים מתמודדים בתי המשפט בישראל עם היעדר רישום פורמלי בסכסוכי מקרקעין פנים־משפחתיים בחברה הערבית, שעה שחלק גדול מן המקרקעין אינם מוסדרים או נסמכים על הסכמים ישנים – בעל־פה או ב"יפוי כוח" – שלא דווחו לרשויות המס?
- ב. מהן ההשלכות הכלכליות של "התניית הרישום" בתשלום מיסי מקרקעין, מקום שבו מדובר בעסקה היסטורית משנות השבעים או השמונים של המאה העשרים שלא דווחה במועדה?
- ג. מהו המשקל הראייתי שמעניק בית המשפט להיתר בנייה שנתנה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה, או לתשלומי ארנונה, כראיה לבעלות במקרקעין בהיעדר רישום בפנקסי המקרקעין?

מתודולוגיה ומבנה העבודה

העבודה משלבת ניתוח דוקטרינרי של החקיקה והפסיקה הישראלית עם עיון משווה פונקציונלי. נקודת המוצא המתודולוגית היא כי שאלת "מה דינו של מי שקנה, קיבל במתנה או ירש מקרקעין אך לא נרשם" היא בעיה אוניברסלית, שכל שיטת משפט מודרנית נדרשת לה, וכי

¹ ס' 7(א) לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 (להלן: חוק המקרקעין).

² לקליטת הזכויות שביושר במשפט הארץ־ישראלי ולגלגולן לאחר חוק המקרקעין ראו ע"א 189/95 בנק אוצר החייל בע"מ ל' אהרונוב, פ"ד נג' (4) 199 (1999) (להלן: עניין אהרונוב).

השוואת הפתרונות – ההשעיה האנגלית של הבעלות שביושר, ההפרדה המצרית בין החיוב לקניין, ודרישת התפיסה (קֶבֶץ) השרעית – מאירה את הבחירות של המשפט הישראלי באור ביקורתי.³

פרק א מציג את הרקע הנורמטיבי והמוסדי: עקרון הרישום הקונסטיטוטיו, ההבחנה בין מקרקעין מוסדרים לשאינם מוסדרים, ושורשי תופעת אי־הרישום בחברה הערבית. פרק ב מנתח את ארגז הכלים השיפוטי להכרעה בזכויות בלא רישום: התחייבות לעשות עסקה, דרישת הכתב ויפוי הכוח הבלתי חוזר, עקרון תום הלב, הזכות שביושר, דיני המתנה והרישיון במקרקעין. פרק ג עוסק בממשק שבין הרישום לבין המס – בתנאים הסטוטוריים המתנים רישום בהסדרת חביונות מס ובהשלכותיהם הכלכליות על עסקאות היסטוריות. פרק ד בוחן את המשקל הראייתי של היתרי בנייה, תשלומי ארנונה וראיות נסיבתיות אחרות. פרק ה מוקדש למשפט המשווה – המשפט המקובל, המשפט המצרי והמשפט השרעי – ולניתוח השוואתי. הפרק המסכם מציע מסקנות והמלצות.

הערה מקדימה אחת על היקף התופעה: תופעת אי־הרישום בחברה הערבית איננה שולית. היא פרי מפגש בין מורשת קרקעית עות'מאנית ומנדטורית, הסדר זכויות שלא הושלם בחלק מן היישובים, דפוסי בעלות משפחתיים־קולקטיביים ("מושאע"), חשש היסטורי מרישום ומחביונות מס, ופרקטיקה מושרשת של העברות בתוך המשפחה שלא בדרך הפורמלית. על רקע זה, ההכרעה השיפוטית בסכסוך פנים־משפחתי אינה אך ורק טכני של דיני הקניין; היא הכרעה בין שיטת רישום מודרנית לבין סדר קנייני מסורתי חי ופעיל.⁴

פרק א: הרקע הנורמטיבי – רישום, הסדר ואי־רישום בחברה הערבית

א.1 עקרון הרישום הקונסטיטוטיו ומדרג הזכויות

חוק המקרקעין, התשכ"ט-1969, עיצב את דיני הקניין הישראליים סביב מרשם המקרקעין. "עסקה במקרקעין" מוגדרת בסעיף 6 לחוק כהקניה של בעלות או של זכות אחרת במקרקעין לפי רצון המקנה, למעט הורשה על פי צוואה;⁵ וסעיף 7(א) קובע את הכלל היסודי: "עסקה במקרקעין טעונה רישום; העסקה נגמרת ברישום". סעיף 7(ב) משלים: עסקה שלא נגמרה ברישום "רואים אותה כהתחייבות לעשות עסקה".⁶ משמעות הדברים היא שהמסמך החוזי – יהא זה הסכם מכר, תצהיר מתנה או יפוי כוח בלתי חוזר – אינו מקנה כשלעצמו בעלות; הוא מקים לכל היותר זכות אובליגטורית כלפי המקנה, וההקניה הקניינית נדחית עד הרישום.

הרישום אינו רק תנאי לגמר העסקה; הוא גם מקור כוחה הראייתי של הזכות. סעיף 125(א) לחוק קובע כי רישום בפנקסים לגבי מקרקעין מוסדרים מהווה "ראיה חותכת לתכנון", בכפוף לחריגים מצומצמים, ואילו לגבי מקרקעין לא מוסדרים הרישום הוא ראיה לכאורה בלבד.⁷ על שני

³ לגישה הפונקציונלית במשפט משווה ראו Konrad Zweigert & Hein Kötz, An Introduction to Comparative Law (Tony Weir trans., 3d ed. 1998) 34–47.

⁴ על דפוסי הקרקע והמושאע ראו להלן פרק א.3 והמקורות הנזכרים שם.

⁵ ס' 6 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 (להלן: חוק המקרקעין).

⁶ ס' 7 לחוק המקרקעין.

⁷ ס' 125 לחוק המקרקעין.

אלה נשען מנגנון תקנת השוק שבסעיף 10 לחוק: מי שרכש זכות במקרקעין מוסדרים בתמורה ובהסתמך בתום לב על הרישום – זכותו שרירה אף אם הרישום לא היה נכון.⁸ תכליתו של מבנה זה כפולה: ודאות קניינית כלפי צדדים שלישיים, והעמדת מרשם אמין שעליו יכול הציבור להסתמך.

ואולם, בצד הקשיחות הקניינית הכיר המחוקק עצמו בכלי ביניים המגשרים על הפער שבין החיוב לקניין. הבולט שבהם הוא הערת האזהרה: משהוכח כי בעל מקרקעין התחייב בכתב לעשות עסקה או להימנע מעשייתה, רשאי הרשם לרשום הערת אזהרה, ואין נפקא מינה אם ההתחייבות נכללה בהסכם, ב"הרשאה בלתי חוזרת" או במסמך אחר.⁹ משנרשמה ההערה, לא תירשם עסקה סותרת, ועיקול מאוחר לא יפגע בזכויות הזכאי.¹⁰ הערת האזהרה איננה שקולה לרישום הזכות עצמה, אך היא צמצמה במידה ניכרת את סיכוני הביניים – למי שטרם לרשמה. בסכסוכים הפנים-משפחתיים שבמוקד עבודה זו, על פי רוב, איש לא רשם דבר: לא זכות ולא הערה.

א.2 מקרקעין מוסדרים ושאינם מוסדרים

שיטת הרישום הישראלית היא שיטה דואלית. לצד פנקסי הזכויות של המקרקעין המוסדרים – פרי הליכי הסדר לפי פקודת הסדר זכויות במקרקעין [נוסח חדש], התשכ"ט-1969, שמקורם בפקודת קרקעות (סידור זכות הקניין) המנדטורית משנת 1928 – מתקיימים פנקסי שטרות של מקרקעין לא מוסדרים, שהרישום בהם ראייתי בלבד וניתן לסתירה.¹¹ הליך ההסדר נועד לברר אחת ולתמיד את הזכויות בקרקע: תביעות מוגשות לפקיד ההסדר, מתבררות, ובסופו של ההליך נערך לוח זכויות והזכויות נרשמות רישום ראשון. סעיף 81 לפקודת ההסדר מורה כי הרישום בעקבות ההסדר מבטל כל זכות הסותרת אותו, בכפוף לחריגים שבפקודה – הוראה דרמטית, שהפכה את אי-ההשתתפות בהליכי ההסדר לאובדן זכויות של ממש.¹²

חשיבות ההבחנה לענייננו כפולה. ראשית, ביישובים ערביים לא מעטים – בגליל, במשולש ובנגב – הליכי ההסדר לא הושלמו עד היום, או שהושלמו תוך רישום קרקעות על שם המדינה ורשות הפיתוח, באופן שהותיר תושבים המחזיקים בקרקע דורות בלא רישום על שמם. שנית, גם במקום שההסדר הושלם, הרישום ההיסטורי קפא לא אחת על שם אבי המשפחה או סבה, בעוד שבפועל חולקו החלקות בין הצאצאים בהסכמות פנימיות שלא באו זכר להן במרשם. בשני המצבים, המרשם אינו משקף את "האמת הקניינית" החיה של המשפחה, והפער הזה הוא חממת הסכסוכים.¹³

⁸ ס' 10 לחוק המקרקעין. הפסיקה הדגישה כי הגנת תקנת השוק מותנית בהשלמת הרישום בפועל, וכי מי שלא נרשם אינו נהנה ממנה: ת"א (מחוזי חי') 18-10-64669 בדארנה ל' בדארנה (נבו 9.1.2022).

⁹ ס' 126 לחוק המקרקעין. לניתוח מוסדי של ההערה ראו אוריאל רייכמן "הערת האזהרה – מהות, יצירה והגנה כנגד עסקות נוגדות" עיוני משפט י' 297 (1984).

¹⁰ ס' 127 לחוק המקרקעין.

¹¹ פקודת הסדר זכויות במקרקעין [נוסח חדש], התשכ"ט-1969. לרקע ההיסטורי ראו חיים זנדברג *הסדר זכויות במקרקעין בארץ-ישראל ובמדינת ישראל* (תש"ס).

¹² ס' 81 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין [נוסח חדש], התשכ"ט-1969.

¹³ על הליכי ההסדר שלא הושלמו ועל תוצאותיהם בחברה הערבית ראו אורן יפתחאל, סנדי קדר ואחמד אמארה "עין מחדש בהלכת 'הנגב המת': זכויות קניין במרחב הבדואי" משפט וממשל יד 7 (2012); רונת לוין-שנור "הפרטה, הפרדה והפליה – זניחת ההליכים של הסדר הזכויות במקרקעין במזרח ירושלים" עיוני משפט לד 183 (2011); לעיל ה"ש 11.

א.3 שורשי אי-הרישום בחברה הערבית: מן המושאע אל יפוי הכוח

תופעת אי-הרישום בחברה הערבית אינה "עצלות רישומית"; היא תוצר היסטורי ומבני. תחת השלטון העות'מאני סווגו הקרקעות על פי חוק הקרקעות העות'מאני משנת 1858 לקטגוריות – מולק, מירי, נקף, מתרקה ומנואת – כאשר עבירת קרקעות מסוג מירי חייבה רישום בספרי הטאבו (טאפו).¹⁴ אלא שבפועל נמנעו רבים מרישום – בשל מס הרישום, החשש מגיוס לצבא ומחשיפה לשלטונות, והנוהג לרישום קרקעות על שם נציג המשפחה או התמולה. דפוס ה"מושאע" – בעלות משותפת בלתי מחולקת שבה מוחזקות החלקות במשותף ומעובדות ברטציה או בחלוקה פנימית מוסכמת – הנציח אף הוא את הפער בין ההחזקה בפועל לבין הרישום.¹⁵

על מצע היסטורי זה נשתלו, לאחר קום המדינה, שלושה גורמים מודרניים. הראשון – דיני המס: רישום עסקה מותנה, כפי שיפורט בפרק ג, בדיווח לרשויות מיסוי מקרקעין ובתשלום המסים הנגזרים, ובמשפחות שבהן העסקאות נעשו לפני עשרות שנים ולא דווחו, עלולת ההסדרה (מס, ריבית, הצמדה וקנסות) מרתיעה מרישום עד עצם היום הזה. השני – התרבות המשפטית הפנים-משפחתית: העברות בין אב לבניו, בין אחים או אגב נישואין נתפסות כעניין משפחתי שאינו טעון פורמליזציה, ולכל היותר נערך יפוי כוח נטריוני בלתי חוזר "ליום פקודה". השלישי – מגבלות תכנוניות המקשות על פיצול חלקות ורישום חלוקות בעין. התוצאה המצטברת: שכבות של עסקאות – מכר, מתנה, ירושה, חלוקה – שכולן "תלויות באוויר" האובליגטורי, ואין נראות במרשם.¹⁶

עדות אמפירית עדכנית לעומק התופעה מצויה במחקר שוק המקרקעין: מחקר שנערך לאחרונה ביישובים ערביים ודרוזיים בישראל מצא כי שוק הקרקעות המקומי מתפקד כתת-שוק נבדל, המעוצב במידה מכרעת על ידי עסקאות פנים-משפחתיות בלתי פורמליות וזכויות קניין בלתי מוסדרות, במנותק ממנגנוני השוק הרגילים.¹⁷ בסכסוך פנים-משפחתי טיפוסי מתייצבים אפוא לפני בית המשפט צדדים שאיש מהם אינו רשום, או שהרשום הוא מוריש משותף שנפטר לפני עשרות שנים. כלי ההכרעה חייבים להילקח משכבות שונות של השיטה: דיני החוזים והקניין, דיני היושר, דיני המתנה והירושה, ודיני הראיות. אלה יידונו כעת.

¹⁴ חוק הקרקעות העות'מאני, 1858. לתרגום האנגלי המקובל ראו F. Ongley, The Ottoman Land Code (1892). ראו להלן פרק ה.3 לדין בקטגוריות אלה ובמורשתן.

¹⁵ לתיאור המושאע והשפעתו על דיני הקרקעות ראו Kenneth W. Stein, The Land Question in Palestine, 1917–1939 (1984); Amos Nadan, "Colonial Misunderstanding of an Efficient Peasant Institution: Land Settlement and Musha' Tenure in Mandate Palestine, 1921–47," 46 J. Econ. & Soc. Hist. Orient 320 (2003) וכן זנדברג, לעיל ה"ש 11.

¹⁶ לפרקטיקה של יפוי כוח בלתי חוזרים כתחליף מעשי לרישום ראו יהושע ויסמן "יפוי-כוח בלתי-חוזר כתחליף לבעלות" משפטים יד 572 (תשמ"ה); ולביקורת על השימוש בהרשאה בלתי הדירה לביצוע מתנה ראו גד טדסקי "הרשאה בלתי-הדירה לביצוע מתנה לאדם שלישי" משפטים יט 205 (תשמ"ט).

¹⁷ Nasr Kheir & Boris A. Portnov, "Land Market Segmentation Along Ethnic Lines: Four Urban Localities in Israel as a Case Study," 136 Land Use Policy art. 106916 (2024).

פרק ב: הכלים המשפטיים והראייתיים להכרעה בזכויות בלא רישום

ב.1 עסקה שלא נגמרה ברישום: מהתחייבות אובליגטורית לזכות מעין-קניינית

נקודת המוצא הדוקטרינרית נקבעה בסעיף 7(ב) לחוק המקרקעין: עסקה שלא נגמרה ברישום רואים אותה כהתחייבות לעשות עסקה. לכאורה, לרוכש או למקבל המתנה שלא נרשמו אין אלא זכות חוזית כלפי המקנה. ואולם, בפסק הדין המתנה בעניין אהרונוב שב בית המשפט העליון והעניק לזכות זו ממד קנייני-מהותי: משנכרת חוזה מכר מחייב, קמה לקונה "זכות שביושר תוצרת הארץ" – זכות מעין-קניינית הפועלת כלפי צדדים שלישיים מסוימים – ולפיכך עיקול שהוטל על ידי נושה של המוכר לאחר ההתחייבות אינו גובר על זכות הקונה, אף אם הקונה לא רשם הערת אזהרה.¹⁸ הרציונל הוא שהנושה המעקל אינו "רוכש" הראוי להגנת ההסתמכות על המרשם: הוא בא בנעלי החייב, ואינו יכול ליטול ממנו יותר משיש לו.

הלכת אהרונוב יושמה במישרין גם על מקבל מתנה בתוך המשפחה: בעניין לוי נ' ח'ג'אזי הוחלה ההלכה על התחייבות אב, ביפוי כוח משנת 1986, להעביר במתנה מקרקעין לשבעת ילדיו – התחייבות שלא הושלמה ברישום – והועדפה זכות הילדים על פני עיקולים שהטילו נושי האב לאחר מכן.¹⁹ חשיבותה של ההלכה לענייננו מכרעת: היא ההופכת את המחזיק הבלתי רשום – אותו בן משפחה שקנה, קיבל או "חולק לו" מגרש לפני עשרות שנים – מבעל טענה חוזית גרידא לבעל מעמד קנייני מהותי, המוגן מפני נושי המקנה. בה בעת, הזכות שביושר איננה בעלות: היא נסוגה מפני רוכש מאוחר בתמורה ובתום לב שהשלים את הרישום, כמצוות סעיף 9 לחוק המקרקעין.²⁰

ב.2 דרישת הכתב ויפוי הכוח הבלתי חוזר

סעיף 8 לחוק המקרקעין מציב דרישת צורה מהותית: התחייבות לעשות עסקה במקרקעין טעונה מסמך בכתב.²¹ בסכסוכים הפנים-משפחתיים שלפנינו, המסמך היחיד הקיים על פי רוב אינו חוזה ערוך כדין אלא יפוי כוח נוטריוני בלתי חוזר, שנחתם לפני עשרות שנים לטובת הקונה או המקבל. השאלה אם יפוי כוח כזה ממלא את דרישת הכתב הוכרעה בחיוב עקרוני: בעניין נאטור נקבע כי יפוי כוח יכול לקיים את דרישת סעיף 8 כאשר עולים ממנו הפרטים המהותיים של העסקה – זהות הצדדים, זיהוי הממכר, טיב העסקה והתמורה – ומשתקפת בו גמירות דעת.²² בדומה, בעניין

¹⁸ ע"א 189/95 בנק אוצר החייל בע"מ נ' אהרונוב, פ"ד נג(4) 199 (1999) (להלן: עניין אהרונוב).

¹⁹ ע"א 1516/99 לוי נ' ח'ג'אזי, פ"ד נה(4) 730 (2001).

²⁰ ס' 9 לחוק המקרקעין. להתנגשות בין התחייבויות נוגדות בעסקאות מתנה משפחתיות ראו בע"מ 2311/22 פלזי נ' פלזי (נבו 13.4.2022), שם הובהר כי עצם החזקת יפוי כוח בלתי חוזר אינה מעניקה עדיפות על התחייבות מוקדמת יותר.

²¹ ס' 8 לחוק המקרקעין. הדרישה פורשה כמהותית ולא ראייתית: ע"א 726/71 גרוסמן את.ק.ב.ק. בע"מ נ' מנהלי עזבון בידרמן, פ"ד כו(2) 781 (1972).

²² ע"א 3205/00 נאטור נ' יאסין, פ"ד נה(4) 145 (2001).

לוי' נ' ח'ג'אזי' הודגשה ההבחנה בין הפן ההרשאתי של ייפוי הכוח לבין הפן החוזי שעשוי להתלוות אליו: ייפוי הכוח עשוי לשמש הן ראייה לעסקת היסוד הן מסמך המגלם אותה, הכל לפי תוכנו.²³

הלכות אלה יושמו במישרין על ייפוי כוח ותיקים מן המגזר הערבי. בעניין אבו אסמעיל אישר בית המשפט העליון כי ייפוי כוח בלתי חוזר המפרט את הצדדים, את המקרקעין, את החלק הנמכר ואת התמורה עשוי לכלול בגדרו הן את עסקת היסוד הן את ההרשאה לביצועה;²⁴ ובפסיקת הערכאות הדיוניות בצפון נדונו ייפוי כוח משנות השבעים ממש: בית משפט השלום בנצרת קבע כי ייפוי כוח בלתי חוזר משנת 1970, הכולל את הממכר, התמורה, זהות הצדדים וההרשאה לרישום, משמש גם התחייבות בכתב כמשמעה בסעיף 8.²⁵ ההיגיון ברור: בחברה שבה ייפוי הכוח הנוטריוני היה "שטר המכר" המעשי, שלילת נפקותו החוזית הייתה מפקיעה למפרע דור שלם של עסקאות.

עם זאת, אין ייפוי הכוח חזות הכל. ראשית, ככלי הרשאה הוא כפוף לדיני השליחות: רק ייפוי כוח שניתן "להבטחת זכותו של אדם אחר", כאמור בסעיף 14(ב) לחוק השליחות, התשכ"ה-1965, אינו פוקע בביטולו של השולח או במותו – ושאלת סיווגו של מסמך קונקרטי היא שאלה פרשנית נכבדה.²⁶ שנית, כותרת "בלתי חוזר" אינה מילת קסם. בעניין צ'מבלר עמד בית המשפט העליון על כך שיש לבחון אם המסמך משקף עסקה של ממש; שם, בעסקה משנת 1963, משהוכח כי שולמה תמורה, כי נמסרה החזקה וכי הרוכשת נהגה בדירה מנהג בעלים עשרות שנים, הוכרה זכותה שביושר חרף היעדר רישום, ונקבע כי תביעתה אינה מתיישנת כל עוד לא כפר המוכר או חליפו בזכותה.²⁷ שלישית, ייפוי הכוח אינו מקנה את הגנות הרישום: מי שלא השלים את הרישום אינו נהנה מתקנת השוק שבסעיף 10, וזכותו נותרת חשופה לעסקה נוגדת שנרשמה בתום לב.²⁸

ב.3 עקרון תום הלב ו"זעקת ההגיונות": ריכוך הצורה בסכסוך המשפחתי

מה דינם של אותם מקרים – שכיחים בסכסוך הפנים-משפחתי – שבהם אין אפילו ייפוי כוח, אלא הסכמה בעל-פה שקוימה בפועל? כאן נכנסת לפעולה הלכת קלמר נ' גיא. באותה פרשה נכרת בעל-פה הסכם קומבינציה, הצדדים קיימוהו במלואו – הבתים נבנו והחזקות נמסרו – ורק אז נטען להיעדר מסמך בכתב. בית המשפט העליון אכף את העסקה: לשיטת הנשיא ברק, עקרון תום הלב שבסעיף 12 לחוק החוזים עשוי, במקרים מיוחדים שבהם עולה "זעקת ההגיונות", לגבור על דרישת הכתב; לשיטת השופט זמיר, ביצעו המלא של ההסכם בפועל ממלא את תכליות הדרישה.²⁹ הלכה זו – שנועדה מלכתחילה למנוע שימוש ציני בדרישת הצורה – היא כלי מרכזי בסכסוכים משפחתיים, שבהם יחסי האמון הם ההסבר הטבעי להיעדר המסמכים, והסתמכות רבת-שנים (בניית בית, השקעה, מגורים) היא שיוצרת את זעקת ההגיונות.

²³ עניין לוי' נ' ח'ג'אזי', לעיל ה"ש 19.

²⁴ ע"א 3274/18 אבו אסמעיל נ' סלימאן (נבו 28.7.2020).

²⁵ ת"א (שלום נצ') 18-06-19781 אבו ליל נ' פארום (נבו 18.10.2023).

²⁶ ס' 14(ב) לחוק השליחות, התשכ"ה-1965. לדיון היסודי בשאלה אם ייפוי כוח בלתי חוזר מעמיד את הקונה במעמד שווה ערך לבעלים ראו ויסמן, לעיל ה"ש 16; אהרן ברק *חוק השליחות* כרך ב (מהדורה שנייה, 1996).

²⁷ ע"א 1559/99 צ'מבלר נ' תורג'מן, פ"ד נז(5) 49 (2003).

²⁸ עניין בדארנה, לעיל ה"ש 8.

²⁹ ע"א 986/93 קלמר נ' גיא, פ"ד נ(1) 185 (1996). לדרישת הכתב וגלגוליה ראו נילי כהן "צורת החוזה" הפרקליט לח 383 (תשמ"ט).

ודוק: הפסיקה הקפידה לשמור על חריגותיה של ההלכה. נדרשות נסיבות עוצמתיות – ביצוע בפועל, הסתמכות ניכרת, חלוף זמן – ואין די בטענה בעלמא להסכמה משפחתית. בכך משורטט האיזון: דרישת הכתב ממשיכה למלא תפקיד הרתעתי-ראייתי, אך אין היא ניתנת לניצול כדי להתנער מהסכמות שהמשפחה חיה על פיהן דורות.

ב.4 התחייבות לתת מתנה, ייפוי כוח בלתי חוזר וזכות החזרה

חלק ניכר מן ההעברות הפנים-משפחתיות אינן מכר אלא מתנה: אב "הרושם" בעל-פה מגרש לבנו, סב המחלק את אדמותיו לנכדיו. חוק המתנה, התשכ"ח-1968, מבחין בין מתנה שהוקנתה לאלתר לבין התחייבות לתת מתנה בעתיד, הטעונה מסמך בכתב.³⁰ כל עוד לא שינה המקבל את מצבו בהסתמך על ההתחייבות, רשאי הנותן לחזור בו – זולת אם ויתר בכתב על זכות החזרה; ובהתנהגות מחפירה של המקבל או בהרעה ניכרת במצבו הכלכלי של הנותן, קמה זכות חזרה נוספת.³¹

כאן נודעת לייפוי הכוח הבלתי חוזר נפקות כפולה ומכרעת. ראשית, כמסמך בכתב הוא עשוי לגלם את ההתחייבות עצמה. שנית – וחשוב מכך – הפסיקה רואה בו, על פי לשונו ונסיבותיו, ויתור בכתב על זכות החזרה שלפי סעיף 5(ב).³² צירופם של השניים – התחייבות בכתב וויתור על חזרה – מקנה למקבל המתנה המשפחתי מעמד איתן באופן מפתיע: בערכאות המשפחה נפסק כי ייפוי כוח בלתי חוזר מוקדם לטובת שלושה אחים גובר על עסקת מתנה מאוחרת שנרשמה לטובת אחד מהם בלבד, עד כדי ביטול הרישום המאוחר.³³ זהו היפוך מרשים של נקודת המוצא הרישומית: המסמך הבלתי רשום מכריע את הרישום, מכוח סעיף 9 לחוק המקרקעין ועקרון תום הלב.

יוער כי שורשי הפרקטיקה נטועים בדיון הקודם: בתקופת המג'לה לא הקנתה התחייבות לתת מתנה זכות ממשית למקבל, אך מסירת החזקה – ולפי הפרקטיקה אף בצירוף ייפוי כוח בלתי חוזר – השלימה את המתנה גם ללא רישום.³⁴ הזיכרון המוסדי הזה – שלפיו "ייפוי כוח + חזקה = העברה גמורה" – מוסיף להזין את הפרקטיקה המשפחתית עד היום, אף שהדין הישראלי החליף מאז את כלליו.

ב.5 רישיון במקרקעין: ההגנה על מי שאין בידו דבר

בתחתית מדרג הכלים ניצב הרישיון במקרקעין – יציר הפסיקה שנועד למי שאינו יכול להצביע אף על התחייבות: בן המשפחה שהתגורר או בנה על קרקע הרשומה על שם קרובו, בהסכמה שבשתיקה, לעיתים עשרות שנים. תורת הרישיון, כפי שנותחה במאמרה הקלאסי של נינה זלצמן,

³⁰ ס' 5(א) לחוק המתנה, התשכ"ח-1968. במקרקעין כפופה ההתחייבות גם לס' 8 לחוק המקרקעין. ראו מרדכי אלפרדו ראבילי *חוק המתנה, תשכ"ח-1968* 331-346 (פירוש לחוקי החוזים מיסודו של ג' טדסקי, מהדורה שנייה, תשנ"ז).

³¹ ס' 5(ב)-5(ג) לחוק המתנה; ראבילי, לעיל ה"ש 30, בעמ' 344 ואילך.

³² עמ"ש (מחוזי מר') 52601-10-23 א.א. ל. אר. א. (נבו 1.11.2024); ראבילי, לעיל ה"ש 30, בעמ' 345-346; והשווה גד טדסקי "הרשאה בלתי-הדירה לביצוע מתנה לאדם שלישי" משפטים יט 205 (תשמ"ט).

³³ תמ"ש (משפחה ת"א) 18541-01-22 *פלונים נ' אלמונים* (נבו 15.1.2023).

³⁴ ראבילי, לעיל ה"ש 30, בעמ' 333-337; להשלמת מתנה בקבלת החזקה ראו גם להלן פרק ה.3 לענין דרישת הקבץ' (התפיסה) במשפט השרעי.

מבחינה בין רשות חנם הדירה לבין רישיון בלתי הדיר שניתן בתמורה או שנוצרה לגביו הסתמכות שהשקעה בצדה.³⁵ הפסיקה הכירה בכך שבנסיבות שבהן הורשה אדם לבנות את ביתו על מקרקעי הזולת והשקיע בהם על יסוד ההרשאה, עשוי הרישיון להיות בלתי הדיר, או למצער להתנות את ביטולו בפיצוי על ההשקעות.³⁶

ואולם, הרישיון הוא זכות אישית במהותה: הוא אינו עובר בירושה, ובפסיקה נקבע כי רשות חנם פוקעת ככלל עם מות בעל הרישיון ואינה מקנה ליורשיו מעמד.³⁷ משמעות הדבר בסכסוך הבין-דורי היא שהרישיון מגן על הדור שקיבל את ההרשאה, אך אינו יכול לשמש תשתית לתביעת בעלות של הדור השלישי. בכך נבדל הרישיון מן הזכות שביושר: הראשון הוא מגן; השנייה – חרב.

ב.6 התיישנות, חזקה רבת-שנים וטענת הבעלות הנוגדת

כלי אחרון, ותיק ובעייתי, הוא טענת ההתיישנות מכוח חזקה נוגדת. במקרקעין לא מוסדרים עשייה חזקה בת חמש עשרה שנים (ולמקרקעין שנרשמו לאחר הסדר – עשרים וחמש שנים) להקים מחסום מפני תביעת הבעלים, ואילו במקרקעין מוסדרים נשללה ההתיישנות כליל.³⁸ בסכסוכים פנים-משפחתיים ערכה של הטענה מוגבלת: חזקתו של בן משפחה נתפסת על פי רוב כחזקה מכוח הרשאה – "חזקה מרשות" – ולא כחזקה נוגדת הצוהלת כנגד הבעלים, ולכן אין היא מבשילה להתיישנות רוכשת. דווקא ההרמוניה המשפחתית, המאפיינת את השלב הראשון של ההסדר הפנימי, שוללת מן המחזיק את פירות החזקה כאשר פורץ העימות כעבור דור.³⁹

ב.7 המערך הראייתי: כיצד מוכיחים עסקה בת חמישים?

בצד הדוקטרינה פועלת מערכת ראייתית. תובע המבקש להוכיח זכות במקרקעין לא רשומים חייב לשכנע במאזן ההסתברויות כי נעשתה עסקה וכי קוימה. הדין מציב מכשול ראייתי נוסף, שכיח מאוד בסכסוכי ירושה: בתביעה נגד עיזבון אין לפסוק על סמך עדותו היחידה של בעל הדין בלא סיוע – שהרי המקנה המקורי אינו עוד בין החיים ואינו יכול להזים.⁴⁰ בפועל נשקלים: המסמך הישן וגלגוליו (יפוי כוח, קבלות, שטר מסורתי), רציפות ההחזקה והשימוש, עיבוד וגידור, בניית בית מגורים, ידיעת בני המשפחה והתנהגותם רבת-השנים, תשלומי מסים והיטלים, והתכתבויות עם הרשויות. פסיקת בתי המשפט לענייני משפחה בצפון הארץ משקפת את המלאכה: הכרעות המבוססות על צירוף של יפוי כוח ותיק, עדויות זקני המשפחה, וראיות שימוש והחזקה מתמשכות.⁴¹ למשקלם המדויק של היתרי בנייה ותשלומי ארנונה יוקדש פרק ד.

³⁵ נינה זלצמן "רישיון במקרקעין" הפרקליט מב 24 (תשנ"ה).

³⁶ ע"א 463/79 ג'בראן נ' ג'בראן, פ"ד לו(4) 403 (1982); ע"א 496/82 רוזן נ' סלונים, פ"ד לט(2) 337 (1985).

³⁷ ע"א 483/16 יהודאי נ' חלמיש – חברה ממשלתית-עירונית לדיר, לשיקום ולהתחדשות שכונות בתל-אביב בע"מ (נבו) 3.10.2017.

³⁸ ס' 5 (2) ו-20 לחוק ההתיישנות, התשי"ח-1958; ס' 159 (ב) לחוק המקרקעין; וס' 78 לחוק הקרקעות העות'מאני לעניין טענות חזקה היסטוריות. לניתוח מקיף ראו יעקב שקד פינוי מקרקעין – הליכים והלכות פרק שנים-עשר (2014).

³⁹ שקד, לעיל ה"ש 38; וראו זלצמן, לעיל ה"ש 35, לעניין היחס בין רישיון לחזקה.

⁴⁰ ס' 54 (4) לפקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א-1971.

⁴¹ ראו למשל תלה"מ (משפחה נצ') 60777-07-20 ג.ס. נ' מ.ד. (נבו) 2021; תמ"ש (משפחה נצ') 4821-07 ג.ע. נ' ע. (נבו) 2012; עניין אבו ליל, לעיל ה"ש 25.

פרק ג: "התניית הרישום" במס – עסקאות היסטוריות שלא דווחו והשלכותיהן הכלכליות

ג.1 המנגנון הסטטוטורי: אין רישום בלא הסדרת המס

שער הכניסה למרשם המקרקעין עובר דרך רשות המסים. חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963, אינו מסתפק בהטלת מס על מכירת זכות במקרקעין; הוא כורך את תוקפה הקנייני של העסקה ואת רישומה בהסדרת החבות. סעיף 16 לחוק קובע כי תוקפן של מכירת זכות במקרקעין ופעולה באיגוד מקרקעין מותנה במילוי חובות ההצהרה והתשלום, וכי עסקה לא תירשם בפנקסי המקרקעין אלא אם אישר המנהל שהיא פטורה ממס או שהמס המגיע שולם.⁴² לענייננו חשובה במיוחד ההוראה המכוונת אל הפרקטיקה של יפוי הכוח: אין תוקף לפעולה שהיא יפוי כוח לטובת הקונה או לפקודתו, אלא אם יפוי הכוח – או העתק נוסריני שלו – הופקד אצל מנהל מיסוי מקרקעין במועד הקבוע בחוק.⁴³ לצד אלה עומדות חובות ההצהרה על כל מכירה בתוך המועדים הקבועים בחוק,⁴⁴ ודרישת תעודת הרשות המקומית – המעידה על סילוק חובות הארנונה והיטל ההשבחה – כתנאי לרישום ההעברה בפנקסים.⁴⁵

שיטת המס אף רחבה מדיני הקניין: "מכירה" לצורך חוק מיסוי מקרקעין נבחנת על פי תוכנה הכלכלי, והיא לזכדת גם הענקת זכויות אובליגטוריות וזכויות שביושר שלא נרשמו מעולם. די בהתחייבות מחייבת כדי להצמיח "יום מכירה" ולהעמיד את החבות במס על מכונה, אף שהקניין טרם עבר.⁴⁶ התוצאה המבנית מרתקת: דווקא מפני שהמס "רואה" את העסקה הבלתי רשומה, נוצר פער בין שני מרשמים – מרשם הזכויות, שבו העסקה אינה קיימת, ומרשם המס, שבו היא הייתה אמורה להיות מדווחת זה מכבר.

ג.2 העסקה ההיסטורית שלא דווחה: אנטומיה של חוב

טלו עסקה טיפוסית: בשנת 1978 מכר – או העניק – אב לבנו מגרש בכפר, כנגד יפוי כוח בלתי חוזר שנחתם אצל נטריון. איש לא הצהיר לרשויות; הבן בנה את ביתו וחי בו. בחלוף ארבעים וחמש שנים, כשהנכדים מבקשים להסדיר את הרישום – אם לצורך משכנתה, אם בעקבות סכסוך – מתעוררות שלוש שכבות של חבות: מס השבח (או מס המתנה ההיסטורי, לפי הדין שחל במועד העסקה) בגין המכירה המקורית; מס הרכישה; והפרשי הצמדה, ריבית וקנסות בגין אי-ההצהרה, המצטברים ממועד העסקה.⁴⁷ בחלק מן המקרים עצם שחזור העסקה קשה: הצדדים המקוריים נפטרו, שווי השוק דאז אינו מתועד, והשאלה אם העסקה הייתה מכר בתמורה או מתנה פטורה בין קרובים שנויה במחלוקת בין הירשמים עצמם – מחלוקת שיש לה נפקות מס ישירה.

⁴² ס' 16 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963 (להלן: חוק מיסוי מקרקעין).

⁴³ ס' 16(ב) לחוק מיסוי מקרקעין. המחוקק זיהה כבר בשנות השישים את יפוי הכוח כמסלול עוקף-דיווח, וביקש ללכוד גם אותו ברשת ההצהרה.

⁴⁴ ס' 73 לחוק מיסוי מקרקעין.

⁴⁵ ס' 324(א) לפקודת העיריות [נוסח חדש]; ולעניין היטל השבחה – ס' 10 לתוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965.

⁴⁶ להגדרות "זכות במקרקעין" ו"מכירה" ראו ס' 1 לחוק מיסוי מקרקעין; ולעקרון המהות הכלכלית ראו אבי גורמן ושי אהרונוביץ' מיסוי מקרקעין – פרשנות, הלכה ומעשה פרק ראשון (2017).

⁴⁷ לקנסות בגין אי-הגשת הצהרה ולהפרשי הצמדה וריבית ראו פרק אחד-עשר לחוק מיסוי מקרקעין; גורמן ואהרונוביץ', לעיל ה"ש 46.

חשוב לדייק במעמדה המשפטי של "התניית הרישום": אי־הדיווח אינו מאיין את העסקה במישור האזרחי שבין הצדדים. הפסיקה ריככה את הוראת סעיף 16 ופירשה אותה כך שהעדר דיווח משעה את תוקפה של המכירה אך אינו שולל אותו לצמיתות – ההצהרה ניתנת להגשה באיחור, והעסקה מבשילה למפרע.⁴⁸ המשמעות המעשית בסכסוך המשפחתי כפולה: מחד גיסא, נתבע אינו יכול להיבנות מטענה שהעסקה "בטלה" רק מפני שלא דווחה; מאידך גיסא, התובע שזכה בהצהרה על זכויותיו יגלה כי בין פסק הדין לבין הרישום חוצץ עדיין מסך המס – פסק הדין המצהיר על הזכות אינו פוטר מהסדרת החבויות כתנאי לרישום.

ג.3. ההשלכות הכלכליות: מעגל הקסמים של אי־הרישום

התניית הרישום במס יוצרת תמריץ שלילי מובהק. ככל שחולף הזמן, עלות ההסדרה גדלה – החוב ההיסטורי צובר הצמדה וריבית, שרשרת ההעברות מתארכת (שכן כל חוליה בלתי מדווחת גוררת שומה נפרדת), ומספר בעלי העניין מתרבה עם כל דור יורשים. משפחות מגלות כי כדי לרשום את הנכד יש להסדיר תחילה את עסקת הסב. התוצאה היא "נעילה" (lock-in): דווקא המשפחות שהיו זקוקות ביותר לוודאות קניינית נדחקות אל מחוץ למרשם, וההון הקנייני שלהן נותר "הון מת" – נכסים שאינם ניתנים למשכון, לביטוח ולמימוש שוקי.⁴⁹

למעגל הזה נודעת גם השלכה ראייתית ישירה על הסכסוך המשפחתי: אי־הדיווח ההיסטורי מקשה על הטוען לעסקה להציג את סממני האמינות שמערכת המס מספקת בדרך כלל – שומה עצמית מזמן אמת, אישורי תשלום, הצהרות חתומות. בהיעדרם, נאלץ בית המשפט להישען על הראיות הנסיבתיות שיידונו בפרק הבא. ומנגד, טענת יורש כי "אילו הייתה עסקה, הייתה מדווחת" – טענה שובת לב לכאורה – זוכה בפסיקה למשקל מוגבל, שכן אי־הדיווח היה, כמתואר, נורמה חברתית רחבה ולא אינדיקציה לפיקטיביות העסקה הקונקרטית.⁵⁰ נשוב לשאלת המדיניות – האם ראוי לנתק את הרישום מן המס, כפי שעשתה מצרים ברפורמה של 2022 – בפרק ה ובסיכום.

פרק ד: היתר בנייה, ארנונה וראיות נסיבתיות – משקלן בהוכחת הזכות

ד.1. מדוע היתר בנייה אינו שטר בעלות

בסכסוכים פנים־משפחתיים נשמעת תדיר הטענה: "אני הוצאתי את היתר הבנייה – סימן שהקרקע שלי". הטענה מפתה אך מוקשית מיסודה. מוסדות התכנון אינם ערכאה קניינית: הוועדה המקומית בוחנת התאמה תכנונית, ואישורה אינו הכרעה בזכויות. תקנות התכנון והבנייה מסדירות מי רשאי להגיש בקשה להיתר ומחייבות הודעה לבעלי זכויות אחרים, אך הן עצמן מורות כי אין בהוצאת ההיתר כדי לקבוע זכויות במקרקעין.⁵¹ ההיתר משקף אפוא, לכל היותר, את העובדה

⁴⁸ לפרשנות המרכזת של ס' 16 ראו גורמן ואהרונוביץ', לעיל ה"ש 46, והפסיקה הנסקרת שם.

⁴⁹ למונח "הון מת" ראו Hernando de Soto, *The Mystery of Capital: Why Capitalism Triumphs in the West and Fails Everywhere Else* (2000). דה־סוטו פיתח את הניתוח על יסוד עבודת שדה במצרים, שבה נאמד שיעור הנכסים המוחזקים בלא רישום ביותר מ-90%; ראו להלן פרק ה.2.

⁵⁰ השוו עניין צ'מבלר, לעיל ה"ש 27, שבו לא נזקפה ההתנהלות הבלתי פורמלית רבת־השנים לחובת הרוכשת.

⁵¹ תק' 36–38 לתקנות התכנון והבניה (רישוי בניה), התשע"ו-2016; וקודם לכן תק' 2א לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל-1970. ההלכה חזרה והדגישה כי מוסדות התכנון אינם מכריעים בסכסוכי

שמבקשו הצליח להציג לרשות תשתית לכאורית של זיקה לנכס באותה עת – חתימת בעלים רשום, יפוי כוח, או היעדר התנגדות מצד בני המשפחה.

דווקא בכך טמון ערכו הראייתי העקיף. בהקשר הפנים־משפחתי, שבו העסקאות נעשות בעל־פה, שתיקת המשפחה בזמן אמת היא ראיה רבת משמעות: אם בשנת 1985 בנה האח את ביתו על החלקה, הגיש בקשה להיתר, פרסם אותה כדין, ואיש מן האחים – שידעו על הבנייה וראוה בעיניהם – לא מחה ולא התנגד, הרי שהתנהגות זו תומכת בגרסה כי החלוקה המשפחתית הנטענת אכן הוסכמה. ההיתר אינו מקור הזכות; הוא תיעוד בן־הזמן של הסכמה חברתית שאבדה מאז. ברוח זו נהגו בתי המשפט לשקול היתרי בנייה, תשלומי היטלים ואישורי רשויות כחלק ממכלול ראייתי התומך בקיומה של הרשאה או זכות – אך לא כראיה עצמאית מכרעת.⁵²

ד.2 ארנונה: ראיה להחזקה, לא לבעלות

חשבונות הארנונה סובלים ממגבלה מובנית עוד יותר. הארנונה מוטלת על "המחזיק" בנכס – בעל הזיקה הקרובה ביותר אליו – ולא על הבעלים דווקא.⁵³ רישומו של אדם כמשלם הארנונה מלמד אפוא על החזקה ועל הכרת הרשות המקומית בו כמחזיק – ותו לא. ואולם, גם כאן, בהצטברות נסיבות, נודע לתשלומים משקל: תשלום ארנונה רצוף במשך עשרות שנים, על שמו של הטוען לזכות, בידיעת יתר בני המשפחה ובלא שדרשו מעולם דמי שימוש או מחו – מתיישב עם גרסת ההחזקה מכוח זכות, ומקשה על הגרסה שלפיה הייתה ההחזקה "ברשות גרידא" שניתנה מחסד.

ההבחנה החדה עולה מסעיף 125 לחוק המקרקעין עצמו: במקרקעין מוסדרים הרישום הוא ראיה חותכת, ושום צבר של קבלות ארנונה והיתרים אינו יכול לגבור עליו במישור הקנייני הטהור – הוא יכול, לכל היותר, לבסס עילות שביושר, רישיון או התחייבות המקימות זכויות כלפי הרשום. במקרקעין לא מוסדרים, לעומת זאת, הרישום ניתן לסתירה, וראיות ההחזקה, העיבוד, הבנייה והתשלומים הן הזירה הראייתית המרכזית שבה מוכרעת השאלה מי הבעלים.⁵⁴

ד.3 מדרג ראייתי מוצע

מן הפסיקה ניתן לחלץ מדרג בלתי פורמלי של ראיות בסכסוך המשפחתי על מקרקעין לא רשומים. במדרגה העליונה – מסמך בן־זמן המגלם את העסקה: יפוי כוח בלתי חוזר מפורט, שטר מסורתי, קבלות תשלום, ובלבד שאמיתותם הוכחה. במדרגה השנייה – ביצוע גלוי ורצוף: מסירת חזקה, בנייה, עיבוד, גידור, מגורים רבי־שנים בידיעת הכל. במדרגה השלישית – התיעוד המנהלי הנסיבתי: היתרי בנייה, תשלומי ארנונה והיטלים, מכתבים לרשויות, רישומים אצל רשות מקרקעי ישראל או חברה משכנת. ובמדרגה הרביעית – עדויות בעל־פה של בני משפחה, הנבחנות

קניין.

⁵²ראו פסיקת ערכאות המשפחה שנסקרה לעיל, לעיל ה"ש 41; ולמשקל ההשקעה והבנייה בהסכמה ראו עניין ג'ברא, לעיל ה"ש 36.

⁵³ס' 269 ו-326 לפקודת העיריות [נוסח חדש]. שוכר, בר-רשות ואף פולש עשויים להירשם כמחזיקים לצורכי ארנונה.

⁵⁴ס' 125 לחוק המקרקעין; שקד, לעיל ה"ש 38, לענין הוכחת החזקה ושימוש רב-שנים.

בזהירות יתרה נוכח האינטרס והזמן שחלף, ובכפוף לדרישת הסיוע בתביעות נגד עיזבון.⁵⁵ אין מדובר במדרג נוקשה: כוחו של כל מקבץ ראיות במצטבר, והעיקרון המנחה הוא קוהרנטיות – מידת התאמתן של הראיות מכל המדרגות לסיפור עובדתי אחד. כאשר יפיו הכוח משנת 1970, הבית שנבנה בשנת 1975, ההיתר על שם המחזיק, הארנונה ששולמה מאז, ושתיקת האחים במשך יובל – כולם מתיישבים זה עם זה, יכריע בית המשפט לטובת המחזיק אף שהמרשם שותק; וכאשר הם סותרים זה את זה, יגבר המרשם.

פרק ה: משפט משווה – המשפט המקובל, המשפט המצרי והמשפט השרעי

שלוש השיטות שנבחרו להשוואה מייצגות שלושה פתרונות ארכיטיפיים לבעיית הזכות הבלתי רשומה: המשפט המקובל האנגלי פיצל את הבעלות לשני רבדים – משפטי ושביישר – והפקיד את הרובד השני בידי דיני היושר; המשפט המצרי, נאמן למסורת הקונטיננטלית, הפריד הפרדה חדה בין החיוב לקניין והפקיר את הרוכש הבלתי רשום למישור האובליגטורי, תוך שהפרקטיקה פיתחה מנגנוני עקיפה משוכללים; והמשפט השרעי, שקדם לרעיון המרשם המודרני, העמיד את התפיסה הפיזית – הקבץ – במרכז ההקניה. כל אחת מן השיטות מאירה פן אחר של הדין הישראלי.

ה.1 המשפט המקובל (Common Law)

ה.1.1 הבעלות שביישר: החוזה כמקור קניין

אבן הפינה של הדין האנגלי בסוגייתנו הונחה במאה התשע-עשרה: משנכרת חוזה מכר מקרקעין הניתן לאכיפה בעין, הופך המוכר לנאמן של הקונה, והקונה – לבעלים שביישר, עוד בטרם הועברה הבעלות המשפטית. כך נפסק בעניין *Lysaght v Edwards*: מות המוכר בין כריתת החוזה להשלמתו אינו מעלה ואינו מוריד, שכן הזכות שביישר כבר עברה לקונה.⁵⁶ ובעניין *Walsh v Lonsdale* הוטבע הכלל הנודע "היושר רואה כעשוי את שראוי היה להיעשות": הסכם לחכירה שלא נחתם בשטר כדין נאכף כאילו נחתם, משום שדיני היושר גוברים על דיני המשפט המקובל.⁵⁷ זהו המקור הרעיוני הישיר של הלכת *אהרונב* הישראלית: "הזכות שביישר תוצרת הארץ" היא נכדתה המוצהרת של הבעלות שביישר האנגלית, לאחר שסעיף 161 לחוק המקרקעין ביקש לנתק את השיטה ממקורות היושר האנגליים והפסיקה השיבה אותם דרך הדלת המקומית.⁵⁸

ה.1.2 המרשם, "פער הרישום" והזכויות הגוברות

המשפט האנגלי המודרני אימץ מרשם זכויות ריכוזי, וחוק רישום המקרקעין משנת 2002 קובע – בדומה לסעיף 7 לחוק הישראלי – כי דיספוזיציה טעונה רישום "אינה פועלת במשפט" עד שמולאו דרישות הרישום.⁵⁹ בפרק הזמן שבין השלמת העסקה לרישומה – "פער הרישום" – אין לרוכש אלא זכות שביישר. אלא שהדין האנגלי, בשונה מן הישראלי, העניק לקטגוריה שלמה של זכויות בלתי

⁵⁵ ס' 54(4) לפקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א-1971.

⁵⁶ *Lysaght v Edwards* (1876) 2 Ch D 499 (Ch).

⁵⁷ *Walsh v Lonsdale* (1882) 21 Ch D 9 (CA).

⁵⁸ ס' 161 לחוק המקרקעין ("אין זכות במקרקעין אלא לפי חוק"); עניין *אהרונב*, לעיל ה"ש 18.

⁵⁹ Land Registration Act 2002, s 27.

רשומות כוח לגבור אף על רכש רשום: "הזכויות הגוברות" (overriding interests), ובראשן זכותו של מי שמצוי בתפיסה ממשית של המקרקעין. בפרשת *Boland* הוחלה ההגנה על אישה שתרמה לרכישת בית שנרשם על שם בעלה בלבד: זכותה שביושר, בצירוף מגוריה בבית, גברה על הבנק הממשכן.⁶⁰ ההקבלה לענייננו מתבקשת: בן המשפחה הערבי המתגורר עשרות שנים בבית שבנה על חלקת המשפחה הוא בדיוק "המחזיק בתפיסה ממשית" שהדין האנגלי בחר להגן עליו מפני קונה חיצוני – הגנה שהמשפט הישראלי מעניק רק בעקיפין, דרך תום הלב הנדרש מן הרוכש השני לפי סעיף 9.⁶¹

ה.3.1 רכישה בלתי פורמלית בתוך המשפחה: נאמנות משתמעת והשתק קנייני

את מקומם של יפוי הכוח והעסקה בעל־פה הישראליים ממלאים באנגליה שני מוסדות יושר. הראשון – הנאמנות המשתמעת מכוונה משותפת (common intention constructive trust): מקום שבני זוג או בני משפחה רכשו והחזיקו נכס במשותף, נלמדות זכויותיהם המהותיות ממכלול התנהלותם – תרומות, כוונות, אורח חיים – ולא מן הרישום בלבד.⁶² השני – ההשתק הקנייני (proprietary estoppel), שפותח במיוחד בסכסוכי ירושה חקלאיים: מי שעבד שנים ארוכות במשק המשפחתי על יסוד הבטחות – אף מרומזות – כי יירש אותו, והסתמך עליהן לרעתו, זכאי לסעד קנייני. בעניין *Thorner v Major* הוכרה זכותו של בן משפחה שעבד שלושים שנה בלא שכר על יסוד רמיזות עקיפות;⁶³ ובעניין *Guest v Guest* קבע בית המשפט העליון הבריטי כי נקודת המוצא לסעד היא הגשמת הציפייה שהובטחה – ירושת המשק – ולא פיצוי על ההסתמכות בלבד.⁶⁴ הדמיון לעובדות המקרים הישראליים – הבן שבנה על חלקת אביו, האח שעבד את האדמה בהבטחה שתהיה שלו – מפתיע בעוצמתו: הלכת קלמר הישראלית ו"זעקת ההגינות" הן, מבחינה פונקציונלית, השתק קנייני ללא השם.

ה.4.1 מתנות, צורה ויפוי כוח בלתי חוזר

בדיני המתנה מחזיק המשפט המקובל בכלל נוקשה: "היושר לא ישלים מתנה פגומה" – הבטחת מתנה ללא תמורה אינה אכיפה, והקניית מקרקעין במתנה טעונה שטר (deed) ורישום.⁶⁵ ואולם גם כאן פיתחו דיני היושר חריצים: הלכת *Re Rose* קובעת כי משעשה הנותן כל שבידו להעברת הזכות, המתנה שלמה ביושר אף בטרם הרישום;⁶⁶ ובעניין *Pennington v Waine* הרחיק בית המשפט לכת והשלים מתנה שטרם נמסרה, מטעמי מצפון בלבד.⁶⁷ אשר לייפוי הכוח – הדין

⁶⁰ *Williams & Glyn's Bank Ltd v Boland* [1981] AC 487 (HL); והמשכה של ההגנה כיום ב-Land Registration Act 2002, sch 3, para 2.

⁶¹ לביקורת עדכנית על מוסד הזכויות הגוברות כסדק ב"עקרון המראה" של המרשם ראו Chris Bevan, "Overriding Interests under the Land Registration Act 2002: Time to Repair the 'Cracked Mirror'?" [2024] Conv. 123.

⁶² *Stack v Dowden* [2007] UKHL 17, [2007] 2 AC 432; *Jones v Kernott* [2011] UKSC 53, [2012] 1 AC 776.

⁶³ *Thorner v Major* [2009] UKHL 18, [2009] 1 WLR 776.

⁶⁴ Alex Waghorn, "Promises in Equity and at Law" *Guest v Guest* [2022] UKSC 27, [2022] 3 WLR 911; Law: Proprietary Estoppel after *Guest v Guest* (2023) 86 MLR 1504; Brian Sloan, "Proprietary Estoppel in the Supreme Court: Banquo's Ghost?" (2023) 82 CLJ 13.

⁶⁵ Law of Property (Miscellaneous Provisions) Act 1989, ss 1–2. את הכלל האנגלי שלפיו הבטחת מתנה גרידא אינה מעבירה בעלות וטעונה מסירה.

⁶⁶ *Re Rose* [1952] Ch 499 (CA).

⁶⁷ *Pennington v Waine* [2002] EWCA Civ 227, [2002] 1 WLR 2075.

האנגלי צר ומדויק: חוק ייפוי הכוח משנת 1971 מכיר בייפוי כוח בלתי הדיר רק כשניתן להבטחת זכות קניינית של מיפיה הכוח או חיוב כלפיו, ואז אין הוא פוקע אף במות המרשה.⁶⁸ באנגליה לא צמחה, אפוא, פרקטיקה של "מכר בייפוי כוח": הזכות שביושר הנובעת מן החוזה עצמו ייתרה את הצורך במכשיר עוקף, והמרשם הנגיש והזול לא הרתיע מרישום. זהו שיעור ראשון במחיר שגובה חסם רישומי: מקום שהרישום קל – ההון המשפטי זורם אליו; מקום שהוא יקר ומסורבל – הוא זורם לעוקפיו.

ה. המשפט המצרי

ה.2.1 העיקרון: אין קניין בלא רישום – והמציאות: אין רישום

הקוד האזרחי המצרי משנת 1948, פרי עטו של עבד אל-רזאק אל-סנהורי, הגדיר את המכר כחוזה אובליגטורי – התחייבות המוכר להעביר את הבעלות כנגד מחיר –⁶⁹ וקבע, בסעיף 934, כי הבעלות בזכויות מקרקעין אינה עוברת – לא בין הצדדים ולא כלפי צדדים שלישיים – אלא בהתאם לחוק הפומביות המקרקעית. חוק הרישום (חוק מס' 114 לשנת 1946) משלים בסעיף 9: כל דיספוזיציה היוצרת, מעבירה או מפקיעה זכות קניינית במקרקעין טעונה רישום, ובהיעדרו אין לעסקה אלא תוקף של חיובים אישיים בין הצדדים.⁷⁰ עד כאן – תאומו של סעיף 7 לחוק המקרקעין הישראלי. אלא שבמצרים הפער בין הדין למציאות הוא תהום: על פי הצהרת שר המשפטים המצרי בדינוי הפרלמנט בשנת 2022, למעלה מ-90% מן הנכסים במצרים אינם רשומים, ונתוני הבנק העולמי מלמדים כי שיעור הרישום נותר נמוך מ-10% גם לאחר הרפורמות.⁷¹

ה.2.2 הפרקטיקה: מכר בייפוי כוח בלתי הדיר ותביעות האימות

בחלל שבין הדין למציאות צמחה במצרים אותה פרקטיקה עצמה המוכרת לנו מן החברה הערבית בישראל – והיא שם שיטת ההעברה הדומיננטית: המוכר אינו רושם דבר, אלא מעניק לקונה "תַּקְיִל" – ייפוי כוח בלתי הדיר – המסמך אותו לעשות בנכס כבשלו, לרבות רישומו על שמו ביום מן הימים. הבסיס הדוקטרינרי מצוי בסעיף 715 לקוד האזרחי: שליחות שניתנה לטובת השלוח או לטובת צד שלישי אינה ניתנת לביטול בלא הסכמת הנהנה – ממש כסעיף 14(ב) הישראלי.⁷² לצד ייפוי הכוח פיתח הדין המצרי שתי תביעות ייחודיות: "תביעת אימות החתימה" (דעוא צחת אל-תוקיע) – הליך שמרני שבו מאשר בית המשפט אך את אמיתות חתימת המוכר, בלא לבחון את תוקף העסקה; ו"תביעת התוקף והנפקות" (דעוא צחה ונפאד) – שבה מוצהר על תוקפו של חוזה המכר הבלתי רשום, ורישום כתב התביעה עצמו משריין לקונה עדיפות: פסק הדין שיירשם יוחס

⁶⁸ Powers of Attorney Act 1971, s 4. זהו המקור ההיסטורי של ס' 14(ב) לחוק השליחות הישראלי.

⁶⁹ ס' 418 לקוד האזרחי המצרי (חוק מס' 131 לשנת 1948).

⁷⁰ ס' 934 לקוד האזרחי המצרי; ס' 9 לחוק ארגון הפומביות המקרקעית, חוק מס' 114 לשנת 1946. במצרים פועלות במקביל שתי שיטות רישום: רישום שטרות פרסונלי לפי חוק 114/1946, החולש על מרבית המדינה, ורישום זכויות קדסטרי לפי חוק מס' 142 לשנת 1964, שתחולתו מוגבלת.

⁷¹ "More than 90% of Egypt's Properties Are Unregistered: Justice Minister," Daily News Egypt (Feb. 14, 2022); "Egypt's Property Registration Rate Remains Below 10%...: World Bank," Daily News Egypt (July 5, 2026). הרנדו דה-סוטו ביסס על מצרים את מחקר "ההון המת" שלו: לעיל ה"ש 49.

⁷² ס' 715 לקוד האזרחי המצרי. בית המשפט החוקתי העליון של מצרים שב ואישר בשנת 2021 כי ייפוי כוח כזה אינו ניתן לביטול חד-צדדי. ואולם ס' 714 מורה כי השליחות פוקעת במות השולח – נקודת תורפה מרכזית של הפרקטיקה, שפסיקת בית המשפט לקסאציה בעניינה אינה אחידה.

אחורנית למועד רישום התביעה.⁷³ סימס אף מרחיק לכת וטוען כי מערכת התחליפים הזו מספקת בפועל ביטחון קנייני סביר – טענה מאלפת לענייננו, שכן היא מזכירה כי השאלה האמיתית אינה "רישום או כאוס" אלא איזו רמת ודאות מספקים מוסדות התחליף.

ה.2.3 הרפורמה של 2020-2022: ניתוק הרישום מן המס

בשנת 2020 ניסתה מצרים לכפות רישום בכוח: תיקון לחוק 114/1946 התנה חיבור נכסים לחשמל, למים ולגז בהוכחת רישום, בצירוף אגרות. פרץ זעם ציבורי – הצעד נתפס כהתניית שירותים חיוניים בתשלום כופר רישומי – והנשיא א־סיסי הורה לדחות את יישום החוק בשנתיים.⁷⁴ בשנת 2022 בא היפוך הגישה: חוק מס' 9 לשנת 2022 קיצר את הליך הרישום לתקרה של 37 ימים, החליף את האגרות היחסיות באגרות קבועות ומתונות – והחשוב מכל: ניתק את הרישום מתשלום מס העסקה, כך שא־הסדרת המס שוב אינה חוסמת את שערי המרשם.⁷⁵ זהו ניסוי מדיניות בעל חשיבות ישירה לישראל: מצרים אבחנה כי צימוד הרישום למס – המנגנון שסעיף 16 הישראלי משכלל – הוא עצמו מנוע מרכזי של א־הרישום, ובחרה לוותר על מנוף הגבייה כדי להציל את המרשם. על הלקח הזה נעמוד בסיכום.

ה.2.4 מקומה של השריעה במשפט המצרי

כינויו של המשפט המצרי בפי רבים "משפט שרעי" מדויק רק בחלקו. חוקת מצרים קובעת אמנם כי "עקרונות השריעה האסלאמית הם המקור הראשי לחקיקה",⁷⁶ וסעיף 1 לקוד האזרחי מציב את עקרונות השריעה כמקור שיורי – לאחר החקיקה והמנהג – להשלמת חסרים.⁷⁷ אך דיני הקניין והחייבים המצריים הם ביסודם קונטיננטליים-צרפתיים בעיצובו של אל־סנהורי, שביקש להניח תשתית אזרחית מודרנית העולה בקנה אחד עם השריעה בלא להיות כפופה לה. השריעה שולטת שליטה מלאה בתחום אחד הקריטי לענייננו – הירושה: חוק הירושה המצרי (חוק מס' 77 לשנת 1943) הוא קודיפיקציה של דיני הפֶּכְאָאֶץ' השרעיים, על מנות היורשים הקבועות שבהם.⁷⁸ צירוף זה – ירושה שרעית קוגנטית מעל מרשם ריק – מוליד במצרים בדיוק את הסכסוך הפנים-משפחתי המוכר מבתי המשפט בנצרת: עיזבון בלתי רשום, מנות שרעיות תיאורטיות, והחזקות בפועל שחילקה המשפחה בדרכה שלה.

⁷³ לפסיקת בית המשפט לקסאציה המצרי על תביעות אלה ראו הסקירות שבמאגרי לשכת עורכי הדין המצרית; ולתיאור אנליטי באנגלית ראו "David Sims, 'Securing Land Tenure in Egypt: Who Needs Registered Titles?' Metropolitica (June 14, 2016).

⁷⁴ "Sisi Orders Delaying Implementation of Controversial Real Estate Law for 2 Years," Ahram Online (Feb. 28, 2021); "Unjust: Egypt's Property Registration Plans Face Popular Backlash," Middle East Eye (2021); לניתוח מדיניות ראו "Real Estate Registration Law Amendments – Development Brief," The Built Environment Observatory (May 2021).

⁷⁵ חוק מס' 9 לשנת 2022 (מצרים), המתקן את חוק מס' 114 לשנת 1946; ראו Shalakany Law Office, "Amendments to Real Estate Registration Law" (2022).

⁷⁶ ס' 2 לחוקת מצרים משנת 2014.

⁷⁷ ס' 1 לקוד האזרחי המצרי. יושם אל לב: המנהג קודם לשריעה במדרג המקורות השיורי.

⁷⁸ חוק הירושה המצרי, חוק מס' 77 לשנת 1943; לצוואות – חוק מס' 71 לשנת 1946, המגביל את חופש הציווי לשליש העיזבון.

ה. המשפט השרעי האסלאמי

ה.3.1 מקורות ושיטה: מן הפקדה אל המג'לה

המשפט השרעי הקלאסי אינו מכיר מרשם זכויות. ההקניה בו נשענת על מעשים גלויים – הצעה, קיבול ותפיסה – והפומביות מושגת בקהילה, לא בפנקס. הקודיפיקציה הנודעת של הדין האזרחי השרעי בנוסחו החנפי היא המג'לה העות'מאנית (מג'לת אל-אחכאם אל-עדליה, 1869–1876), שחלה בארץ ישראל עד לחקיקה הישראלית המודרנית, ובוטלה סופית רק בחוק לביטול המג'לה, התשמ"ד-1984.⁷⁹ לימודה של המג'לה אינו תרגיל היסטורי: הדורות שערכו את יפוי הכוח של שנות החמישים והשישים גדלו על ברכי כלליה, והפרקטיקה המשפחתית הערבית משמרת את דפוסיה עד היום.

ה.3.2 מתנה (הבה) ודרישת התפיסה (קבץ')

ספר המתנות של המג'לה (סעיפים 833–880) מגלם את הדוקטרינה השרעית: המתנה נכרתת בהצעה ובקיבול – אך היא מושלמת רק בתפיסה. סעיף 837 קובע כי "המתנה נכרתת בהצעה וקיבול, ומושלמת בתפיסה"; סעיף 861 – כי המקבל נעשה בעלים של נכס המתנה עם קבלת החזקה; וסעיף 862 – כי הנותן רשאי לחזור בו מן המתנה כל עוד לא נמסרה.⁸⁰ החזקה, לא הכתב ולא הרישום, היא אפוא קו פרשת המים הקנייני. והנה שני כללים משלימים בעלי תהודה ישירה לסכסוך המשפחתי: ראשית, מתנה שהושלמה בין קרובי משפחה מדרגה אוסרת (הורים וצאצאים, אחים ואחיות וילדיהם, דודים ודודות) אינה ניתנת לחזרה כלל;⁸¹ ושנית, מתנת שכיב מרע ליורש טעונה הסכמת שאר היורשים – מחסום מפני עקיפת מנות הירושה ערב המוות.⁸²

כאן מתגלה המפתח ההיסטורי להבנת הפרקטיקה הנחקרת בעבודה זו. תחת המג'לה, אב שמסר לבנו את החזקה בחלקה – השלים את המתנה; שום רישום לא נדרש להשלמת ההקניה בין הצדדים, והחזרה נחסמה הן מחמת הקרבה הן מחמת התפיסה. יפוי הכוח הבלתי חוזר שנוסף לפרקטיקה שימש שכבת ביטחון מנהלית – מכשיר לרישום עתידי אם וכאשר ידרש. במילים אחרות: במונחי הדין שהמשפחות הכירו, "חזקה + יפוי כוח" לא הייתה עסקה חסרה אלא עסקה שלמה. רק חוק המקרקעין הישראלי, בהפכו את הרישום לקונסטטטיבי, הפך למפרע את השלם לחסר – והפער התודעתי הזה הוא המצע העמוק של הסכסוכים הנדונים.⁸³

ה.3.3 שליחות (נפאלה), ירושה שרעית ודפוס המשפחה

גם מוסד יפוי הכוח עצמו שרעי במקורו: ספר השליחות של המג'לה (סעיפים 1449–1530) קובע כי השולח רשאי לסלק את שלוחו – אלא אם נקשרה בשליחות זכותו של אחר, שאז אין הוא

⁷⁹ לתרגום האנגלי המקובל ראו: C.R. Tyser, D.G. Demetriades & Ismail Haqqi Effendi (trans.), *The Mejelle: Being an English Translation of Majallah el-Ahkam-i-Adliya* (1901), התשמ"ד-1984.

⁸⁰ ס' 837, 862–861 למג'לה. לדוקטרינת ההבה הקלאסית ראו Joseph Schacht, *An Introduction to Islamic Law* (1964); Y. Linant de Bellefonds, "Hiba," in *The Encyclopaedia of Islam* (2d ed.).

⁸¹ ס' 866 למג'לה; וכן ס' 872 – מות אחד הצדדים חוסם את החזרה.

⁸² ס' 879 למג'לה; לדיון עדכני ראו Siti Norfatirah Abdul Rahmani & Mohd Zamro Muda, "Ownership Status of Hibah Marad al-Mawt," 34(8) *al-Qanatir Int'l J. Islamic Stud.* (2025).

⁸³ להוראת המעבר ראו ראבילי, לעיל ה"ש 30, בעמ' 333–337, המתאר את הדין ערב חוק המתנה; והשוו. L. Landau, "The Gift Law, 1968," 4 *Isr. L. Rev.* 260 (1969) על החלפת דיני ההבה של המג'לה בחוק המתנה הישראלי.

רשאי עוד לבטלה.⁸⁴ ואילו דיני הירושה השרעיים – הפְּכָאֵץ – מקצים מנות קבועות ליורשים, ובהם מנה לבנות השווה למחצית מנת הבנים.⁸⁵ על רקע זה התפתחו בחברות המוסלמיות דפוסים חברתיים מתעדים היטב: השהיית חלוקת העיזבון דור ומעלה תוך החזקה משותפת בלתי מחולקת; "תִּתְּ אֲרוּג" – הסתלקות יורש ממנתו כנגד פיצוי מוסכם; וויתור מקובל – ולעיתים כפוי חברתית – של נשים על מנותיהן לטובת אחיהן, כדי לשמר את קרקע המשפחה בקו הגברי.⁸⁶ ובמישור הקרקעי, חוק הקרקעות העות'מאני משנת 1858 – שביקש לרשום כל מחזיק מירי בפנקסי הטאפו – נתקל בהתחמקות המונית: איכרים רשמו את אדמותיהם על שם נכבדים או נמנעו מרישום כליל, מחשש מיסוי וגיוס, והדפוס הקולקטיבי של המושאע שרד את הרפורמה.⁸⁷ צירופם של אלה – ירושה קוגנטית, הסדרים פנימיים, וחשד מורשתי כלפי המרשם – הוא הדנ"א ההיסטורי של תיקי המשפחה הנדונים היום בישראל.

ה. ניתוח השוואתי: ארבעה צירים ולקחיהם

הציר הראשון – מעמד הרוכש הבלתי רשום. שלוש השיטות המודרניות מסכימות על נקודת המוצא: אין קניין שלם בלא רישום. אך הן נבדלות תכלית הבדל במה שנותר בידי מי שלא נרשם. באנגליה – בעלות שביושר מלאה, העשויה אף לגבור על רוכש רשום מכוח תפיסה ממשית; בישראל – זכות שביושר "תוצרת הארץ", הגוברת על נושים אך נסוגה מפני רוכש רשום תם לב; במצרים – חיוב אישי בלבד, הנתמך במנגנוני אימות דיוניים. המשפט השרעי ניצב מחוץ לציר: בהיעדר מרשם קונסטיטוטיו, התפיסה עצמה היא ההקניה. הדין הישראלי ממוקם אפוא בתווך שבין לונדון לקהיר – והפסיקה בסכסוכים המשפחתיים מטה אותו, בפועל, לונדונה.

הציר השני – מכשיר העקיפה. כל שיטה הצמיחה תחליף פונקציונלי לרישום, והשוואת התחליפים מאלפת: באנגליה התחליף הוא שיפוט־עקרוני (נאמנות משתמעת והשתק קנייני, הנתפרים למידותיו של כל מקרה); במצרים ובחברה הערבית בישראל – מסמכי־פרטי (יפוי הכוח הבלתי הדיר); ובשריעה – עובד־ת־פִּיזִי (הקבץ). המקבילה המבנית בין מצרים לחברה הערבית בישראל היא הממצא ההשוואתי המרכזי של עבודה זו: אותו מכשיר עצמו, מאותם טעמים עצמם – מרשם יקר, איטי וכרוך במס – ועם אותן נקודות תורפה עצמן: פגיעה במות המרשה, פגיעות לעסקאות נוגדות, והיזקקות בסופו של יום לאישור שיפוטי בדיעבד.

הציר השלישי – ההעברה הפנים־משפחתית. מרתק לגלות ששלוש השיטות פיתחו רגישות מיוחדת דווקא להקשר המשפחתי, אך במנגנונים הפוכים. השריעה מקשיחה את ההקניה (דרישת תפיסה) ומרככת את החזרה (איסור חזרה בין קרובים) – איזון המגן על יציבות ההענקות בתוך המשפחה. האנגלים מרככים את הצורה עצמה: ההשתק הקנייני נולד ופרח בסכסוכי המשק

⁸⁴ ס' 1521 למג'לה. השליחות פוקעת ככלל במות השולח – כלל שהעמיד בסימן שאלה את יפוי הכוח הוותיקים שנועדו לפעול "לאחר אריכות ימים". לניסוח מודרני של דיני הִנְכָּאֵלָה ראו: AAOIFI, Shari'ah Standard No. 23: Agency (2015).

⁸⁵ N.J. Coulson, Succession in the Muslim Family (1971).

⁸⁶ Annelies Moors, Women, Property and Islam: Palestinian Experiences, 1920–1990 (1995); ולפרקטיקה בבתי הדין השרעיים בישראל ראו: Aharon Layish, Women and Islamic Law in a Non-Muslim State (1975).

⁸⁷ Ruth Kark, "Consequences of the Ottoman Land Law: Agrarian and Privatization Processes in Palestine," 101 Societies, Social Inequalities and Marginalization (R. Chand et al. eds., 2017); נדן, לעיל ה"ש 15.

המשפחת, מתוך הכרה שבתוך המשפחה איש אינו עורך חוזים. והדין הישראלי משלב: דרישת כתב קשיחה להלכה, ולצדה שסתומי "זעקת ההגינות", זכות שביושר וויתור בכתב על חזרה ממתנה הגלום בייפוי הכוח. השילוב הישראלי עובד – אך במחיר אי־ודאות ניכר, שכן הוא תלוי כולו בהפעלה שיפוטית בדיעבד של שסתומים עמומים.

הציר הרביעי – היחס בין המרשם למס. כאן מציעה ההשוואה את לקח המדיניות החד ביותר. אנגליה מעולם לא כרכה את הרישום בגביית מסי העסקה במלוא החומרה הישראלית, ומרשמה המקוון זול ומהיר. מצרים כרכה – וקצרה אי־רישום של תשעים אחוזים; משהבינה זאת, ניתקה ב-2022 את הרישום מן המס וקיצצה את אגרותיו. ישראל עודנה מחזיקה בצימוד מלא: סעיף 16 לחוק מיסוי מקרקעין וסעיף 324 לפקודת העיריות מציבים את רשות המסים ואת הרשות המקומית כשוערי המרשם. הניסיון המצרי מלמד שצימוד כזה, ביישומו על אוכלוסייה שבה אי־הרישום הוא נחלת הכלל, אינו מגבה את הגבייה אלא מקבע את אי־הרישום – על כל מחיריו הראייתיים, הכלכליים והחברתיים.⁸⁸

סיכום ומסקנות

לשאלת המחקר הראשונה – כלי ההכרעה בהיעדר רישום – העלה העיון תמונה של ארגז כלים עשיר אך מדורג: הזכות שביושר מכוח הלכת אהרונם היא עמוד השדרה, המקנה למחזיק הבלתי רשום מעמד מהותי מוגן; ייפוי הכוח הבלתי חוזר הוכר הן כמסמך הממלא את דרישת הכתב הן כוויתור על זכות החזרה ממתנה; עקרון תום הלב ו"זעקת ההגינות" משמשים שסתום למקרי הקיצון שבהם אין כל מסמך; הרישיון במקרקעין מגן על מי שהחזיק בהסכמה בלא עסקה; ודיני הראיות – ובכללם דרישת הסיוע בתביעה נגד עיזבון – מסננים את הטענות. ההכרעה השיפוטית הטיפוסית אינה נשענת על כלי יחיד אלא על הצטברות קוהרנטית של מסמך ותיק, ביצוע ממושך וראיות נסיבתיות.

לשאלת המחקר השנייה – התניית הרישום במס – נמצא כי הצימוד הסטטוטורי שבין המרשם לרשות המסים (סעיף 16 לחוק מיסוי מקרקעין וסעיף 324 לפקודת העיריות) פועל על עסקאות היסטוריות כמס רטרואקטיבי מצטבר: חוב השבח, הרכישה, ההצמדה, הריבית והקנסות של עסקת שנות השבעים מוטל כתנאי סף על הדור המבקש להסדיר היום. במישור האזרחי אין באי־הדיווח כדי לאיין את העסקה, אך במישור המעשי הוא מקים "מעגל אי־רישום": ככל שהסדרה נדחית היא מתייקרת, וככל שהיא מתייקרת – היא נדחית. הניסיון המצרי, שבו הוליד צימוד דומה אי־רישום של למעלה מתשעים אחוזים עד שנותק ברפורמת 2022, מלמד כי מדובר בכשל מדיניות מבני ולא בכשל אכיפה.

לשאלת המחקר השלישית – משקלם של היתר הבנייה והארנונה – הוצע בפרק ד מדרג: אלה אינן ראיות בעלות, שכן מוסדות התכנון והגבייה אינם מכריעים בקניין והארנונה נגבית מן המחזיק באשר הוא; אך הן ראיות נסיבתיות רבות ערך להחזקה, להשקעה ולהסכמה המשפחתית שבזמן אמת – ובעיקר לשתיקתם רבת־השנים של בני המשפחה החולקים היום. כוחן במצטבר ובקוהרנטיות שלהן עם יתר הראיות, לא כתחליף רישום.

⁸⁸ראו לעיל פרק 2.3; והשוו Kareem Ibrahim & Deena Khalil, "Land Titling: A Tool, not a Panacea — Insights from Egypt," Metropolitica (Dec. 20, 2016).

במישור ההשוואתי, העבודה חשפה רצף גנאלוגי אחד: מן הקֶבֶץ השרעי, דרך המג'לה וחוק הקרקעות העות'מאני, אל יפוי הכוח הבלתי חוזר של הפרקטיקה הערבית – בישראל כבמצרים – ואל הזכות שביושר שמקורה אנגלי. הסכסוך הפנים־משפחתי על מקרקעין לא רשומים איננו, אפוא, "סטייה" מקומית מן הדין, אלא מפגש בין שלוש תפיסות הקניה היסטוריות החיות בשכבות השיטה: תפיסה פיזית, מסמך פרטי ומרשם ממלכתי. השופט הישראלי המכריע בתיק כזה מיישב, בלא דעת, בין המג'לה לבין חוק המקרקעין.

מן הראוי לחתום בשלוש המלצות מדיניות. **ראשית**, יש לשקול – בעקבות מצרים – ריכוך ממוקד של צימוד המרשם והמס לגבי עסקאות פנים־משפחתיות היסטוריות: הוראת שעה של הקלה בקנסות וברביבית, או מסלול "הסדרה מוזלת", שתמריץ רישום במקום להענישו. **שנית**, ראוי להשלים את הליכי הסדר הזכויות ביישובים הערביים שבהם לא הושלמו, בשיתוף הקהילות ובהכרה בראיות ההחזקה המסורתיות – שאם לא כן יוסיף כל דור להוריש לדור הבא סכסוך גדול משהוריש לו קודמו. **שלישית**, במישור השיפוטי, מוצע לעגן בגלוי את המדרג הראייתי שהותווה בפרק ד, ולהכיר בכך שבסכסוכים אלה "היעדר מסמכים" איננו חשד אלא נורמה תרבותית־היסטורית – כפי שעשה הדין האנגלי בפתחו את ההשתק הקנייני לסכסוכי המשק המשפחתי. המרשם הוא משאת הנפש; אך עד שיגיעו אליו כל בתי החברה הערבית, מוטב שהדרך אליו תהיה גשר – ולא חומה.

ביבליוגרפיה

חקיקה ישראלית

- חוק המקרקעין, התשכ"ט-1969.
- חוק המתנה, התשכ"ח-1968.
- חוק השליחות, התשכ"ה-1965.
- חוק הירושה, התשכ"ה-1965.
- חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963.
- חוק ההתיישנות, התשי"ח-1958.
- חוק לביטול המג'לה, התשמ"ד-1984.
- פקודת הסדר זכויות במקרקעין [נוסח חדש], התשכ"ט-1969.
- פקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א-1971.
- פקודת העיריות [נוסח חדש].
- תקנות התכנון והבניה (רישוי בניה), התשע"ו-2016.
- חוק הקרקעות העות'מאני, 1858.

פסיקה ישראלית

- ע"א 726/71 גרוסמן את ק.ב.ק. בע"מ נ' מנהלי עזבון ב'דרמן, פ"ד כו(2) 781 (1972).
- ע"א 463/79 ג'בראן נ' ג'בראן, פ"ד לו(4) 403 (1982).

ע"א 496/82 רזון נ' סלונים, פ"ד לט (2) 337 (1985).

ע"א 986/93 קלמר נ' גיא, פ"ד נ (1) 185 (1996).

ע"א 189/95 בנק אוצר החייל בע"מ נ' אהרונב, פ"ד נג (4) 199 (1999).

ע"א 1516/99 לוי נ' חיג'אזי, פ"ד נה (4) 730 (2001).

ע"א 3205/00 נאטור נ' יאסין, פ"ד נה (4) 145 (2001).

ע"א 1559/99 צימבלר נ' תורג'מן, פ"ד נז (5) 49 (2003).

רע"א 7060/12 מדינת ישראל נ' United Israel Appeal Inc (נבו 30.4.2015).

ע"א 483/16 יהודאי נ' חלמיש – חברה ממשלתית-עירונית לדיר, לשיקום ולהתחדשות שכונות בתל-אביב בע"מ (נבו 3.10.2017).

ע"א 3274/18 אבו אסמעיל נ' סלימאן (נבו 28.7.2020).

בע"מ 2311/22 פלוני נ' פלוני (נבו 13.4.2022).

ת"א (מחוזי חי') 64669-10-18 בדארנה נ' בדארנה (נבו 9.1.2022).

עמ"ש (מחוזי מר') 52601-10-23 א.א. נ' אר.א. (נבו 1.11.2024).

ת"א (שלום נצ') 19781-06-18 אבו ליל נ' פאהום (נבו 18.10.2023).

תמ"ש (משפחה ת"א) 18541-01-22 פלונים נ' אלמונים (נבו 15.1.2023).

תלה"מ (משפחה נצ') 60777-07-20 ג.ס. נ' מ.ד. (נבו 2021).

תמ"ש (משפחה נצ') 4821-07 ס.ע.ז. נ' ע.ע.ז. (נבו 2012).

ספרות עברית

אהרן ברק *חוק השליחות* (מהדורה שנייה, 1996).

אבי גורמן ושי אהרונוביץ' *מיסוי מקרקעין – פרשנות, הלכה ומעשה* (2017).

יהושע ויסמן *דיני קניין – חלק כללי* (1993).

יהושע ויסמן "פיו-כוח בלתי-חוזר כתחליף לבעלות" משפטים יד 572 (תשמ"ה).

נינה זלצמן "רישיון במקרקעין" הפרקליט מב 24 (תשנ"ה).

חיים זנדברג *הסדר זכויות במקרקעין בארץ-ישראל ובמדינת ישראל* (תש"ס).

גד טדסקי "הרשאה בלתי-הדירה לביצוע מתנה לאדם שלישי" משפטים יט 205 (תשמ"ט).

אורן יפתחאל, סנדי קדר ואחמד אמארה "עיון מחדש בהלכת 'הנגב המת': זכויות קניין במרחב הבדואי" משפט וממשל יד 7 (2012).

נילי כהן "צורת החוזה" הפרקליט לח 383 (תשמ"ט).

רונית לוין-שגור "הפרטה, הפרדה והפליה – זניחת ההליכים של הסדר הזכויות במקרקעין במזרח ירושלים" עיוני משפט לד 183 (2011).

מרדכי אלפרדו ראבילו *חוק המתנה, תשכ"ח-1968* (פירוש לחוקי החוזים מיסודו של ג' טדסקי, מהדורה שנייה, תשנ"ז).

אוריאל רייכמן "הערת האזהרה – מהות, יצירה והגנה כנגד עסקות נוגדות" עיוני משפט י 297 (1984).

חקיקה ופסיקה זרה

Land Registration Act 2002 (UK).
Land Registration Act 1925 (UK).
Law of Property (Miscellaneous Provisions) Act 1989 (UK).
Powers of Attorney Act 1971 (UK).
Lysaght v Edwards (1876) 2 Ch D 499 (Ch).
Walsh v Lonsdale (1882) 21 Ch D 9 (CA).
Re Rose [1952] Ch 499 (CA).
Williams & Glyn's Bank Ltd v Boland [1981] AC 487 (HL).
Pennington v Waine [2002] EWCA Civ 227, [2002] 1 WLR 2075.
Stack v Dowden [2007] UKHL 17, [2007] 2 AC 432.
Thorner v Major [2009] UKHL 18, [2009] 1 WLR 776.
Jones v Kernott [2011] UKSC 53, [2012] 1 AC 776.
Guest v Guest [2022] UKSC 27, [2022] 3 WLR 911.
The Egyptian Civil Code, Law No. 131 of 1948, arts. 1, 418, 714–715, 934.
Real Estate Publicity Law No. 114 of 1946 (Egypt), as amended by Law No. 9 of 2022.
Real Property Registry Law No. 142 of 1964 (Egypt).
Law of Inheritance No. 77 of 1943 (Egypt).
Constitution of the Arab Republic of Egypt (2014), art. 2.
The Mejlle (Majallat al-Ahkam al-Adliyya, 1869–1876), arts. 833–880, 1449–1530 (C.R. Tyser et al. trans., 1901).
The Ottoman Land Code 1858 (F. Ongley trans., 1892).

ספרות זרה

Chris Bevan, “Overriding Interests under the Land Registration Act 2002: Time to Repair the ‘Cracked Mirror’?” [2024] Conveyancer & Property Lawyer 123.
N.J. Coulson, Succession in the Muslim Family (1971).
Hernando de Soto, The Mystery of Capital: Why Capitalism Triumphs in the West and Fails Everywhere Else (2000).
Kareem Ibrahim & Deena Khalil, “Land Titling: A Tool, not a Panacea — Insights from Egypt,” Metropolitix (Dec. 20, 2016), metropolitix.org.
Ruth Kark, “Consequences of the Ottoman Land Law: Agrarian and Privatization Processes in Palestine, 1858–1918,” in Societies, Social Inequalities and Marginalization (R. Chand, E. Nel & S. Pelc eds., 2017).

- Nasr Kheir & Boris A. Portnov, “Land Market Segmentation Along Ethnic Lines: Four Urban Localities in Israel as a Case Study,” 136 *Land Use Policy* art. 106916 (2024).
- L. Landau, “The Gift Law, 1968,” 4 *Israel Law Review* 260 (1969).
- Aharon Layish, *Women and Islamic Law in a Non-Muslim State: A Study Based on Decisions of the Shari‘a Courts in Israel* (1975).
- Y. Linant de Bellefonds, “Hiba,” in *The Encyclopaedia of Islam* (2d ed.).
- Annelies Moors, *Women, Property and Islam: Palestinian Experiences, 1920–1990* (1995).
- Amos Nadan, “Colonial Misunderstanding of an Efficient Peasant Institution: Land Settlement and Musha‘ Tenure in Mandate Palestine, 1921–47,” 46 *Journal of the Economic and Social History of the Orient* 320 (2003).
- Siti Norfatirah Abdul Rahmani & Mohd Zamro Muda, “Ownership Status of Hibah Marad al-Mawt: A Study on the Views of Classical and Contemporary Scholars,” 34(8) *al-Qanatr: International Journal of Islamic Studies* (2025).
- Joseph Schacht, *An Introduction to Islamic Law* (1964).
- David Sims, “Securing Land Tenure in Egypt: Who Needs Registered Titles?” *Metropolitics* (June 14, 2016), metropolitiques.eu.
- Brian Sloan, “Proprietary Estoppel in the Supreme Court: Banquo’s Ghost?” (2023) 82 *Cambridge Law Journal* 13.
- Kenneth W. Stein, *The Land Question in Palestine, 1917–1939* (1984).
- Alex Waghorn, “Promises in Equity and at Law: Proprietary Estoppel after *Guest v Guest*” (2023) 86 *Modern Law Review* 1504.
- Konrad Zweigert & Hein Kötz, *An Introduction to Comparative Law* (Tony Weir trans., 3d ed. 1998).
- AAOIFI, *Shari‘ah Standard No. 23: Agency and the Act of an Uncommissioned Agent* (Fudooli).
- Law Commission, *Updating the Land Registration Act 2002* (Law Com. No. 380, 2018).
- “More than 90% of Egypt’s Properties Are Unregistered: Justice Minister,” *Daily News Egypt* (Feb. 14, 2022), dailynewsegypt.com.
- “Real Estate Registration Law Amendments – Development Brief,” *The Built Environment Observatory* (May 2021), marsadomran.info.
- Shalakany Law Office, “New Amendments to Real Estate Registration Law: Accelerated and Streamlined Registration Procedures” (2022), shalakany.com.